

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1607/2563

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นาย ว. กับพวก
นาย ม.

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 283 ทวิ, มาตรา 317

คำว่า "พา" หมายความว่า นำไปหรือพาไป ส่วนคำว่า "พราง" หมายความว่า การพาไปหรือแยกเด็กออกไปจากอำนาจปกครองดูแล ทำให้อำนาจปกครองดูแลของบิดามารดาเด็กถูกรบกวนหรือถูกระทบกระเทือนโดยบิดามารดาเด็กไม่รู้เห็นยินยอม อันเป็นการมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองอำนาจปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่มีต่อเด็ก มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดด้วยการพาไปหรือแยกเด็กออกจากความปกครองดูแล โดยไม่จำกัดว่ากระทำด้วยวิธีการใดและไม่คำนึงระยะทางใกล้ไกล ความผิดฐานพาและพรางไปเพื่อการอนาจาร สำคัญอยู่ที่ว่าการพาไปหรือแยกเด็กไปนั้นได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้ไปกับบุคคลที่พาไปหรือไม่ หรือมิฉะนั้นบุคคลที่พาเด็กนั้นไปจะต้องมีเหตุอันสมควร

จำเลยจอดรถอยู่ใต้ต้นมะม่วงริมถนนหน้าบ้าน โจทก์ร่วมที่ 3 วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้น จำเลยชวนโจทก์ร่วมที่ 3 เข้าไปดูการ์ตูนในรถด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย จากนั้นอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 เข้าไปในรถให้โจทก์ร่วมที่ 3 นั่งบนตัก และกระทำอนาจารโดยใช้มือล้วงอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 3 โดยปิดประตูแต่เปิดกระจกฝั่งคนขับไว้เพียง 1 ใน 4 ส่วน ก็เพื่อหาโอกาสล่วงละเมิดทางเพศต่อโจทก์ร่วมที่ 3 โดยไม่ให้มีคนอื่นพบเห็น แม้จำเลยไม่ได้พาไปจากบ้านที่เกิดเหตุ โดยรถยังจอดอยู่ห่างจากวงสุราประมาณ 15 เมตร และมีได้ติดเครื่องยนต์ในลักษณะที่จะพาตัวโจทก์ร่วมที่ 3 ไป

ก็ตาม แต่การที่จำเลยชนโจทก์ร่วมที่ 3 ไปกระทำอนาจารราว 40 นาที จนต้องตามหาตัว เป็นการพาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปแล้ว และเป็นการล่วงละเมิดอำนาจปกครองดูแลของโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นบิดามารดาให้ถูกตัดขาดพรากไปแล้วโดยปริยาย โดยปราศจากเหตุอันสมควร

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 279, 283 ทวิ, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานาย ว. ผู้เสียหายที่ 1 นาง ป. ผู้เสียหายที่ 2 และเด็กหญิง ข. โดยนาง ป. ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้เสียหายที่ 3 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 เข้าเป็นโจทก์ร่วมในข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร และให้ผู้เสียหายที่ 3 โดยผู้เสียหายที่ 2 เข้าเป็นโจทก์ร่วมในข้อหาพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร กระทำอนาจาร และกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยให้เรียกผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ว่าโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก, 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปี ส่วนฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีและ

ฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 8 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279, 283 ทวิ และ 317 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 3 อายุ 4 ปีเศษ เป็นบุตรสาวของโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 โจทก์ร่วมทั้งสามพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักด้านหลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห. วันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา โจทก์ร่วมที่ 1 พาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปงานเลี้ยงปีใหม่ ที่บ้านนาง ท. ยายของโจทก์ร่วมที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลดังกล่าว แล้วโจทก์ร่วมที่ 1 เข้าไปร่วมนั่งดื่มสุรากับจำเลยและคนอื่นอีกหลายคนที่ได้ถูกรับของนาง ท. ส่วนโจทก์ร่วมที่ 3 วิ่งเล่นอยู่บริเวณบ้าน ต่อมาเวลาประมาณ 15 นาฬิกา นาง ท. ไม่พบโจทก์ร่วมที่ 3 ทุกคนที่อยู่ในบ้านจึงแยกย้ายกันตามหา นาง อ. ลูกพี่ลูกน้องโจทก์ที่ 2 มองเข้าไปในรถกระบะของจำเลยผ่านกระจกด้านคนขับซึ่งเปิดไว้ประมาณ 1 ใน 4 เห็นโจทก์ร่วมที่ 3 นั่งเล่นโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่บนดักของจำเลยบนเบาะนั่งข้างคนขับ รถกระบะของจำเลยไม่ได้ติดเครื่องยนต์จอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านนาง ท. ซึ่งไม่มีรั้วกั้น โดยโจทก์ร่วมที่ 3 นั่งอยู่กับจำเลยประมาณ 40 นาที ก่อนที่โจทก์ร่วมที่ 1 จะพาโจทก์ร่วมที่ 3 ไป หลังเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 3 เข้ารับการตรวจร่างกายกับ

แพทย์ที่โรงพยาบาล ห. 3 ครั้ง แพทย์ระบุว่า เยื่อพรหมจารีไม่ฉีกขาด แต่มีรอยบวมแดงบริเวณแคมใหญ่ และช่องคลอดอักเสบ สำหรับความผิดปกติกระทำซ้ำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นควรพิจารณาประเด็นที่ว่า จำเลยกระทำอนาจารโจทก์ร่วมที่ 3 หรือไม่เสียก่อน ประเด็นนี้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามมีโจทก์ร่วมที่ 3 เบิกความเป็นพยานยืนยันว่า จำเลยอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 เข้าไปในงบนटकของจำเลยในรถแล้วใช้มือล้วงเข้าไปและใช้นิ้วแหย่อวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 3 โดยโจทก์ร่วมที่ 3 ทำท่าทางประกอบการเบิกความด้วยการใช้มือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศ นอกจากนี้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามยังมีโจทก์ร่วมที่ 2 และนางสาว ศ. พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห. มาเบิกความสนับสนุนได้ความว่า หลังเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 2 สอบถามโจทก์ร่วมที่ 3 ว่าทำไมจึงไปอยู่กับจำเลยในรถ โจทก์ร่วมที่ 3 เล่าว่า จำเลยชวนไปดูการ์ตูนในรถ แล้วใช้มือล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 3 โจทก์ร่วมที่ 3 เจ็บที่อวัยวะเพศ โจทก์ร่วมที่ 2 จึงโทรศัพท์ไปปรึกษานางสาว ศ. และพาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปพบนางสาว ศ. ที่บ้านพักเพื่อตรวจดูอวัยวะเพศ นางสาว ศ. ตรวจพบรอยแดงบริเวณแคมนอก จึงแนะนำให้โจทก์ร่วมที่ 2 พาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาล ห. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอและแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ต่อมาวันที่ 4 มกราคม 2561 โจทก์ร่วมที่ 2 พาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปตรวจที่โรงพยาบาล ห. แพทย์ตรวจพบว่าการอักเสบบวมแดงบริเวณอวัยวะเพศโจทก์ร่วมที่ 2 จึงพาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธร ห. พนักงานสอบสวนส่งโจทก์ร่วมที่ 3 ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 8 มกราคม 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 โจทก์ร่วมที่ 3 ยังคงมีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศ โจทก์ร่วมที่ 2 จึงพาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง เห็นว่า แม้ขณะเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 3 อายุเพียง 4 ปีเศษ สมองยังไม่เจริญ

เต็มที ความสามารถในการสื่อสารอาจถูกจำกัดด้วยภาษาและคำพูด แต่ก็สามารถรับรู้และจดจำเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองรวมทั้งความรู้สึกที่มีและถ่ายทอดสาระสำคัญให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ซึ่งเนื้อหาที่โจทก์ร่วมที่ 3 ให้การและเบิกความพร้อมทำท่าทางเกี่ยวกับการถูกจำเลยกระทำอนาจารก็เป็นเรื่องยากที่เด็กในวัยนั้นจะคิดปั้นแต่งขึ้นเองได้ ประกอบกับคำเบิกความและคำให้การดังกล่าวก็สอดคล้องกับผลการตรวจชันสูตรบาดแผล ซึ่งพบรอยบวมแดงภายนอกช่องคลอดบริเวณแคมใหญ่ ทำให้คำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 3 มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น การที่โจทก์ร่วมที่ 2 พาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอหลังเกิดเหตุประมาณ 4 วัน ก็ไม่ใช่ข้อพิรุธที่จะส่งผลกระทบต่อน้ำหนักและความน่าเชื่อถือของคำเบิกความของโจทก์ร่วมที่ 3 ซึ่งเป็นประจักษ์พยาน เพราะหลังเกิดเหตุโจทก์ร่วมที่ 2 ได้พาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปให้นางสาว ศ. ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจดูเบื้องต้นในวันเกิดเหตุแล้ว และโจทก์ร่วมที่ 3 ยังสามารถวิ่งเล่นได้ไม่มีอาการถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลฉุกเฉิน ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันหยุดปีใหม่ ส่วนที่จำเลยนำสืบโต้แย้งทำนองว่า จำเลยนอนอยู่ที่เบาะนั่งด้านหน้าข้างคนขับโดยเปิดประตูรถด้านนั้นไว้ แต่ปิดประตูด้านคนขับ โจทก์ร่วมที่ 3 มาขอจำเลยดูการ์ตูนในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย จำเลยกล่าวว่าโทรศัพท์จะหายและขณะนั้นมีรถสัญจรบริเวณนั้นจำนวนมาก กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่โจทก์ร่วมที่ 3 จึงอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 ขึ้นมาดูการ์ตูนบนตักและปิดประตูรถฝั่งที่จำเลยนั่งเพราะเกรงว่าโจทก์ร่วมที่ 3 จะลงจากรถ หลังจากนั้นจำเลยกลับ มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่โจทก์ร่วมที่ 1 ตะโกนว่าจำเลยและอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 ออกไปจากรถนั้น เห็นว่า เหตุผลที่จำเลยอ้างในการอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3มานั่งบนตักในรถแตกต่างจากเหตุผลที่จำเลยเคยแถลงต่อศาลชั้นต้นในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 หน้า 2 ซึ่งจำเลยให้เหตุผลว่า ฝนกำลังจะตกจึงให้โจทก์ร่วมที่ 3 เข้าไปดูโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยในรถ ทำให้คำเบิกความของจำเลยขาดความน่าเชื่อถือ ส่วนข้อที่จำเลยอ้างเพื่อปิดประตูรถ

หลังจากอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 ขึ้นมานั่งบนตักแล้วว่าเพื่อให้โจทก์ร่วมที่ 3 ลงจากรถก็ไม่สมเหตุผล เพราะไม่มีเหตุที่จำเลยต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายกับโจทก์ร่วมที่ 3 ในกรณีที่โจทก์ร่วมที่ 3 ต้องการจะลงจากรถ เนื่องจากด้านที่จำเลยนั่งติดกับบริเวณพื้นที่บ้านของนาง ท. ไม่ได้ติดกับฝั่งถนน ในทางตรงข้ามกลับส่อให้เห็นข้อพิรุธในความพยายามที่จะทำให้คนที่อยู่ภายนอกยากแก่การมองเห็นภายในรถ พยานหลักฐานจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามพยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสามว่า จำเลยอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 ไปนั่งบนตักแล้วใช้มือล้วงอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 3 อันเป็นการกระทำอนาจารโจทก์ร่วมที่ 3 คงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพาและพรากโจทก์ร่วมที่ 3 ไปเพื่อการอนาจารหรือไม่ เห็นว่า คำว่า "พา" หมายความว่า นำไปหรือพาไป ส่วนคำว่า "พราก" หมายความว่า การพาไปหรือแยกเด็กออกไปจากอำนาจปกครองดูแล ทำให้อำนาจปกครองดูแลของบิดามารดาเด็กถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระเทือนโดยบิดามารดาเด็กไม่รู้เห็นยินยอมอันเป็นการมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองอำนาจปกครองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่มีต่อเด็ก มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดด้วยการพาไปหรือแยกเด็กออกจากความปกครองดูแลโดยไม่จำกัดว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดและไม่คำนึงระยะทางใกล้ไกล สาระสำคัญอยู่ที่ว่าการพาไปหรือแยกเด็กไปนั้นได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้ไปกับบุคคลที่พาไปหรือไม่ หรือมิฉะนั้นบุคคลที่พาเด็กนั้นไปจะต้องมีเหตุอันสมควร เมื่อจำเลยจอดรถอยู่ใต้ต้นมะม่วงริมถนนหน้าบ้าน โจทก์ร่วมที่ 3 วิ่งเล่นอยู่บริเวณนั้น จำเลยชวนโจทก์ร่วมที่ 3 เข้าไปดูการ์ตูนในรถด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย จากนั้นจำเลยอุ้มโจทก์ร่วมที่ 3 เข้าไปในรถให้โจทก์ร่วมที่ 3 นั่งบนตัก และกระทำอนาจารโดยใช้มือล้วงอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 3 โดยปิดประตู แต่เปิดกระจกฝั่งคนขับไว้เพียง 1 ใน 4 ส่วน ก็เพื่อหาโอกาสล่วงละเมิดทางเพศต่อโจทก์ร่วมที่ 3 โดยไม่ให้มีคนพบเห็น แม้จำเลยไม่ได้พาไปจากบ้านที่เกิดเหตุ โดยรถยังจอดอยู่ห่างจาก

วงสุรประมาณ 15 เมตร และได้ติดเครื่องยนต์ในลักษณะที่จะพาตัวโจทก์ร่วมที่ 3 ไปก็ตาม แต่การที่จำเลยชวนโจทก์ร่วมที่ 3 ไปกระทำอนาจารราว 40 นาที จนต้องตามหาตัวกันเช่นนี้ เป็นการพาโจทก์ร่วมที่ 3 ไปแล้ว และเป็นการล่วงละเมิดอำนาจปกครองดูแลของโจทก์ร่วมที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นบิดามารดาให้ถูกตัดขาดพรากไปแล้วโดยปริยาย โดยปราศจากเหตุอันสมควร จำเลยจึงมีความผิดฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร และฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ โดยมาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 279 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงให้ใช้กฎหมายที่ใช้ขณะกระทำผิดบังคับแก่จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม), 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร จำคุก 5 ปี ส่วนฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีและฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยรวม 5 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ทองธาร เหลืองเรืองรอง-พันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง-บุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายณรงค์ ทองอำไพ
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายไพศาล โกสสวัสดิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>